

1519077-33.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.1. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519077-33.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519077-33.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

KAIQUE DA SILVA ALVES e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

O Ministério Público denunciou KAIQUE DA SILVA ALVES, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 10h, na Rua Vergueiro, altura do nº 1287, Liberdade, São Paulo - SP, teria, em tese, subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares, a bolsa e a quantia de R\$12.000,00 (doze mil reais) pertencentes à vítima A. P. B.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 78/79). O réu foi citado (fls. 133/136), constituiu advogado (fls. 143/144) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 158/180). O Ministério Público apresentou manifestação sobre a defesa apresentada (fls. 257/260).

É a síntese. Decido.

Analisando-se com mais detalhes os autos e respeitado o entendimento ministerial, entende-se que seja o caso de o réu ser absolvido sumariamente pelos motivos a seguir expostos.

Os fatos datam de 06 de novembro de 2020, tendo a vítima informado em 09 de novembro de 2020 sobre as movimentações realizadas em sua conta bancária, tendo

sido transferida a quantia de R\$12.000,00 (doze mil reais) para o réu e R\$17.899,98 (dezesete mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) para Ewerton Moreira Silveira, informações que serviram de base para as investigações. Segundo consta às fls. 10/21, o banco Bradesco forneceu cópia dos documentos do réu, inclusive uma cópia de sua CNH. A vítima, então, foi chamada ao distrito policial para realizar reconhecimento, oportunidade na qual lhe foi exibido apenas a foto do réu (fls. 11 e 16), foto 3x4, em que sequer o réu aparece de corpo inteiro (fls. 18), sendo que se tratava de uma foto com emissão em 2018.

Observa-se que às fls. 03/05, a vítima descreve o autor do roubo como um homem que aparentava ter 25 anos de idade, cutis preta, cabelos castanhos e complexão magra. Posteriormente, em 25 de novembro de 2020, ouvida novamente, apresentou diversos detalhes, como olhar "meio caído", algumas espinhas ou manchas em ambas as faces do rosto, destacando ainda que estava com boné e usava uma máscara (fls. 13). No entanto, é relevante anotar-se que tais detalhes foram relatados APÓS a vítima ter tido contato com a foto do réu (e apenas a foto dele), já que consta expressamente de seu depoimento a informação de que antes de o prestar teve acesso à foto do réu. Diante disso, nota-se que, apesar do reconhecimento fotográfico, houve irregularidade em tal procedimento, porquanto se procedeu com exibição apenas da foto do réu, havendo dúvida razoável quanto ao vício ou influência no reconhecimento, haja vista que em um primeiro momento a vítima não forneceu maiores detalhes, mas após ver a única imagem do réu, forneceu detalhes como espinhas ou manchas, muito embora estivesse de máscara, características estas que consta da foto (única) que lhe foi exibida.

Relevante anotar-se que sequer a foto do outro beneficiário da outra operação bancária feita com o cartão subtraído da vítima (Weverton Moreira Silveira) foi exibida à vítima, tendo a autoridade policial requisitado à instituição bancária apenas a vinda aos autos dos documentos de Kaique, inexistindo qualquer explicação razoável do motivo pelo qual não se adotou a mesma providência com relação a Weverton, tendo havido uma aparente escolha aleatória por parte da autoridade policial, o que é inadmissível. Anoto que quando o ofício de fls. 10 foi expedido, já havia informação sobre as duas movimentações bancárias (fls. 06/07).

Nesse sentido, tem-se que o C.STJ, no HC 598.886/SC, fixou parâmetros para que o reconhecimento em sede policial seja considerado legítimo e passível de ser validado por outro reconhecimento em Juízo. Para tanto, a Corte determinou que os requisitos do artigo 226 do CPP devem ser rigorosamente observados nos atos de reconhecimentos realizados pelas autoridades policiais, tanto nos casos de reconhecimentos pessoais quanto fotográficos. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial,

a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua conseqüente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades

constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

Assim, entendo que houve vício no procedimento de reconhecimento, conforme destacado acima, não havendo certeza quanto ao reconhecimento fotográfico ou mesmo se houve influência pelo fornecimento de uma foto apenas do réu Kaique, motivos pelos quais, com base no atual posicionamento do STJ quanto aos reconhecimentos fotográficos e pessoais, entendo ser o caso de absolvição sumária.

Frise-se que o C.STJ vem trancando ações penais apenas calcadas em reconhecimento fotográfico em sede policial ou reconhecimentos que apresentem vícios, considerando nulos os atos (HC 672185/SP).

Vale destacar, ainda, que no ato de oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu que a autoridade policial fizesse contato com a vítima, a fim de que fossem informados os dados de qualificação de seu marido (fls. 73), que estaria no veículo no momento dos fatos, tendo a vítima dito que não os forneceria e que diante do transcorrer do lapso temporal, não se lembrava mais da fisionomia do roubador (fls. 154).

Além disso, em 13 de julho de 2021, quando compareceu em sede policial para fornecer os comprovantes bancários, enquanto se apurava suposto estelionato, declarou que havia sido ressarcida pelo banco e que não desejava mais representar contra Kaique (fls. 43).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, ABSOLVENDO SUMARIAMENTE KAIQUE DA SILVA ALVES, o que faço com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA